



Roj: **STS 116/2021 - ECLI:ES:TS:2021:116**

Id Cendoj: **28079130022021100010**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **05/01/2021**

Nº de Recurso: **183/2019**

Nº de Resolución: **3/2021**

Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**

Ponente: **NICOLAS ANTONIO MAURANDI GUILLEN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ M 10569/2018,**
ATS 222/2020,
AATS 2419/2020,
STS 116/2021

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 3/2021

Fecha de sentencia: 05/01/2021

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 183/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 15/12/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén

Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.4

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián

Transcrito por: FGG

Nota:

R. CASACION núm.: 183/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 3/2021

Excmos. Sres. y Excmo. Sra.

D. Nicolás Maurandi Guillén, presidente

D. José Díaz Delgado
D. Ángel Aguillo Avilés
D. José Antonio Montero Fernández
D. Francisco José Navarro Sanchís
D. Jesús Cudero Blas
D. Isaac Merino Jara
D^a. Esperanza Córdoba Castroverde

En Madrid, a 5 de enero de 2021.

Esta Sala ha visto el recurso de casación que con el número 183/2019 ante la misma pende de resolución, interpuesto por la entidad JP Morgan European Investment Trust PLC, representada por el procurador don Arturo Romero Ballester y defendida por el abogado don José Manuel Carro Martín, contra la sentencia núm. 480/2018, de 22 de octubre de 2018, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 30/2018).

Siendo parte recurrida la Administración General del Estado representada y defendida el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Nicolás Maurandi Guillén.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia aquí recurrida tiene la siguiente parte dispositiva:

" **FALLO:**

DESESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO interpuesto por el Procurador D. Arturo Romero Ballester, en nombre y representación de JP Morgan European Investment Trust PLC, contra la resolución de 14 de noviembre de 2017 del TEAR por la que se desestima la reclamación económico-administrativa 28/30596/2014, interpuesta contra el acuerdo de liquidación dictado por la Dependencia Regional de Gestión de la Delegación Especial de Madrid de la AEAT en concepto de IRNR (sin establecimiento permanente) y, en consecuencia, CONFIRMAMOS dicha resolución en su integridad.

Con imposición de costas a la parte demandante".

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, por la representación procesal de JP Morgan European Investment Trust PLC, se preparó recurso de casación, y la Sala de instancia lo tuvo por preparado y remitió las actuaciones a este Tribunal con emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones, el auto de 16 de enero de 2020 de la Sección Primera de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo [aclarado por otro posterior de 6 de marzo de 2020] resolvió admitir el recurso de casación y determinar cuál era la cuestión que presentaba interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, lo que efectuó en los términos que se indican más adelante en el apartado de "*fundamentos de derecho*" de la actual sentencia.

CUARTO.- La representación procesal de JP Morgan European Investment Trust PLC presentó el escrito de interposición de su recurso de casación que, tras exponer las infracciones normativas y jurisprudenciales reprochadas a la sentencia recurrida, terminaba así:

" **A LA SALA SUPLICA:** Que teniendo por interpuesto en tiempo y forma el presente recurso de casación, dicte Sentencia por la que anule íntegramente la Sentencia impugnada y declare que una correcta interpretación del Derecho de la Unión Europea exige equiparar la tributación sobre los rendimientos del capital mobiliario percibidos por las IICs armonizados por la Directiva 2009/65/CE, tanto nacionales como establecidos en otros Estados Miembros de la Unión Europea.

Asimismo, suplico que, a resultas de la anulación total de la Sentencia de instancia, esa Sala declare la anulación de los actos administrativos por dicha Sentencia confirmados y, en definitiva, reconozca el derecho a la devolución instada por mi representada junto con los correspondientes intereses de demora".

QUINTO.- El Abogado del Estado también formalizó su oposición al recurso de casación con un escrito en el que hizo constar lo siguiente:

" **2.- OPOSICIÓN AL RECURSO.**

Esta representación, haciendo uso de la habilitación conferida por Providencia de la Sala de 16 de julio de 2020 manifiesta que no existen razones para que la Sala dicte una sentencia de signo diferente del recogido en las sentencias testigo de referencia, esto es las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2019 c. 5405/2017 y 28 de marzo de 2019 c. 5822/2017".

SEXTO.- Se señaló para votación y fallo del presente recurso la audiencia de 15 de diciembre de 2020, y la deliberación continuó el 22 inmediato posterior con el resultado que se expresa en la presente sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Reseña inicial de los hechos y actos administrativos litigiosos y del proceso jurisdiccional seguido en la instancia; e indicación de quien es la parte recurrente en la actual casación.*

A partir de lo consignado en la resolución de 14 de noviembre de 2017 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (TEAR-M) puede señalarse lo siguiente:

1.- La entidad JP Morgan European Investment Trust PLC es una Institución de Inversión Colectiva (IIC), constituida de acuerdo con las leyes británicas y residente fiscal en Reino Unido, a la que le fueron practicadas retenciones a cuenta sobre los dividendos obtenidos por su inversión en acciones cotizadas españolas.

2.- Solicitó a la AEAT, mediante declaración modelo 210/215, la devolución de la cantidad retenida a cuenta del IRNR, al entender que la aplicación de la retención del 15% establecida en el Convenio de doble imposición entre España e Reino Unido constituye una restricción a la libre circulación de capitales, ya que los fondos de inversión residentes en España tributan al 1% en el impuesto sobre Sociedades.

El objeto de esa solicitud fue la devolución de la diferencia, es decir, el 14%.

3.- El órgano gestor inició un procedimiento de comprobación limitada mediante requerimiento de determinada documentación, con el objeto de comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos para atender la devolución solicitada.

En dicho requerimiento se comunicó el inicio de un procedimiento de comprobación limitada que tenía por objeto verificar que se trata de un organismo de Inversión Colectiva en valores regulado en la Directiva 2009/65/GE del Parlamento Europeo y del Consejo; que cumple las mismas condiciones que las I.I.C. españolas; y que tiene su residencia fiscal en Reino Unido.

Y se solicitaban los justificantes de las retenciones soportadas.

4.- Posteriormente, el órgano-gestor notificó acuerdos de liquidación por el concepto de Impuesto sobre la Renta de no residentes, correspondientes a los períodos que a continuación se expresan en los importes que para cada uno de ellos se indica:

Primer trimestre de 2010.....29.158,20 €

Segundo trimestre de 2010..... 90.231,86 €

Tercer trimestre de 2010..... 39.607,50 €

Cuarto trimestre de 2010..... 55.362,57 €

Total:..... 214.360,21€

Y se desestimó la solicitud formulada por considerarse que no se había probado la comparabilidad de la entidad reclamante con las IIC españolas.

5.- Frente a los anteriores acuerdos se plantearon reclamaciones económico-administrativa que, tras su acumulación, fueron desestimadas por resolución de 14 de noviembre de 2017 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (TEAR-M).

La principal razón de decidir de esta resolución fue que a través de la documentación aportada no había resultado acreditado por la entidad reclamante la concurrencia en ella de los elementos que resultan sustanciales para que las IIC puedan aplicar el régimen especial de tributación del Impuesto, sobre Sociedades.

6.- Después se interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la resolución anterior. Y en la posterior demanda se postuló la nulidad de la resolución administrativa inicial que denegó la devolución solicitada y de la posterior resolución del TEAR-M; así como el reconocimiento de la devolución de 214.360,21 euros, junto con los intereses de demora que correspondan.

Ese recurso jurisdiccional fue desestimado por la sentencia que es objeto de esta casación.

7.- El actual recurso de casación ha sido interpuesto también por JP Morgan European Investment Trust PLC .

SEGUNDO.- *La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia según el auto de admisión del recurso de casación de 16 de enero de 2020 (aclarado por el posterior auto de 6 de marzo de 2020).*

La parte dispositiva, tras la aclaración de su texto inicial, decide lo siguiente:

" 2º) Precisar las dos cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia:

a) Determinar si el análisis de comparabilidad entre las instituciones de inversión colectiva residentes en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sin establecimiento permanente en España, y las instituciones de inversión colectiva residentes en España, al objeto de determinar si el diferente tratamiento tributario de los dividendos percibidos de sociedades residentes en España supone o no una restricción a la libre circulación de capitales contraria al Derecho de la Unión Europea, se debe realizar conforme a la legislación española de fuente interna sobre instituciones de inversión colectiva o conforme a la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.

b) Dilucidar si el análisis de la suficiencia de los mecanismos existentes para obtener información sobre los fondos de inversión residentes en Reino Unido debe buscar la identidad con los que España tiene con otros Estados miembros de la Unión Europea o la mera equiparación y la efectividad de los mismos para el fin pretendido, decidiendo, en consecuencia, si la cláusula de intercambio de información prevista en el artículo 26 del Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, hecho en Madrid (...), podía ser suficiente o era claramente insuficiente en el ejercicio 2009.

3º) Identificar como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación el artículo 14.1.l) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en conexión con los artículos 63, 64 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

TERCERO.- *El razonamiento de la sentencia recurrida que resulta relevante para lo que se debate en el actual recurso de casación.*

Se incluye en su fundamento de derecho cuarto, cuyo contenido es el que continúa:

"La cuestión central que se discute en el presente procedimiento consiste en determinar si la actora tiene derecho, respecto de los dividendos percibidos en España, a la aplicación del mismo tipo de gravamen que se encuentra previsto en la normativa interna para las entidades comparables residentes en territorio español y, en relación con ello, si acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación española a las Instituciones de Inversión Colectiva españolas.

La resolución recurrida lo niega argumentando, en esencia, que la diferencia de tributación invocada por la entidad reclamante resulta de comparar la tributación que nuestro Derecho establece para los dividendos obtenidos en España por IIC residentes en España y por entidades como la reclamante, para concluir la interesada que su tributación, con ocasión de la percepción de dividendos en España, incurre en discriminación prohibida por la normativa comunitaria al ser más gravosa que la que hubiera soportado un fondo de inversiones español de análogas características, ya que, a diferencia de lo que ocurre con éstos, no se le han devuelto las retenciones soportadas, siendo su tributación final muy superior al 1% que soportan las rentas obtenidas por los fondos españoles, lo que afirma es contrario al principio de libre circulación de capitales establecido en el artículo 63 del TFUE que prohíbe todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y también entre Estados miembros y terceros países, y añade que dicha discriminación no está justificada.

Añade que, sin embargo, el artículo 65.1.a) del TFUE permite conceder un trato diferente a contribuyentes diferentes.

Por tanto, es claro que no puede afirmarse que haya restricción de la libertad de circulación de capitales, en términos del artículo 63 del TFUE, si la diferencia de trato obedece a diferencias objetivas entre las entidades, residentes y no residentes, cuya tributación se compara.

Por lo que, antes de afirmar la existencia de trato discriminatorio, se debe realizar un análisis de comparabilidad entre la IIC reclamante y las IIC residentes en España, para determinar si cumple los mismos requisitos objetivos que hacen que a éstas se les aplique un régimen fiscal especial que determina la tributación al 1%

en el Impuesto sobre Sociedades, y el diferimiento de la tributación definitiva al momento de percepción de la rentabilidad por los partícipes o accionistas.

La aplicación de dicho régimen especial está condicionado a que la entidad que pretenda su aplicación cumpla los requisitos para ser considerada IIC, lo que obliga a determinar cuáles son las condiciones básicas que la legislación específica exige para adquirir y mantener tal condición, ya que estas mismas condiciones habrán de ser exigidas a las entidades no residentes que pretendan aplicarlo, en este caso a una entidad procedente de Reino Unido.

En cuanto a la carga de la prueba, es evidente que es el reclamante quien tiene toda la disponibilidad y facilidad probatoria a su alcance, ya que se trata de acreditar requisitos de su propia actividad y de su configuración orgánica, y, en su caso, de obtener certificación fehaciente de organismos públicos de su propio país de residencia acerca de dichos requisitos.

Por contra, la administración española carece de las herramientas necesarias para acceder a la información que al contribuyente le será fácil obtener.

La entidad reclamante aportó durante el procedimiento la siguiente documentación:

- certificado de residencia fiscal en Reino Unido.
- modelos 210 del IRNR.
- copia de los certificados de retenciones de los bancos depositarios de las acciones.
- certificado, emitido en idioma inglés sin traducción jurada por la propia entidad reclamante, descriptivo de las características legales, fiscales y financieras del fondo.

A la vista de la documentación aportada, la Oficina Gestora considera que no se han acreditado los elementos que resultan sustanciales para que las IIC españolas puedan aplicar el régimen especial de tributación del Impuesto sobre Sociedades:

* No se ha acreditado que la entidad tenga más de 100 partícipes, requisito de cuyo carácter imprescindible no puede dudarse al ser expresamente exigido por el propio artículo 28.5.b) del TRLIS de 2004, cuya ausencia inicial impide acceder a la condición de IIC, y su pérdida sobrevenida supone incurrir en causa de revocación de la autorización, lo que ocasiona la pérdida del régimen de tributación.

* Tampoco se ha acreditado por parte de la entidad la tenencia del patrimonio o capital social mínimo exigido para las IIC residentes, ni el que se exige para los fondos de inversión de carácter financiero, 3.000.000 euros, con carácter general, ni tampoco el que se exige a las SICAV de 2.400.000 euros.

* No acredita dichos requisitos el certificado emitido por la propia entidad, ya que, además de tratarse de un documento de parte sin valor probatorio alguno, en él no se hace alusión alguna al cumplimiento de los requisitos relativos a la tenencia de más de cien partícipes, ni al capital social mínimo exigido para los fondos de inversión.

La comparación ha de hacerse, no con las pautas generales que resultan de las directivas comunitarias que han regulado la materia, sino con los requisitos concretos que marca la legislación española, cuyo carácter sustancial es claro en la normativa fiscal española, y cuyo incumplimiento impediría el acceso al régimen fiscal español de las IIC residentes en nuestro país.

Porque el mantenimiento de la libertad de circulación de capitales no obliga a los Estados miembros a ser menos exigente con residentes de terceros estados de lo que es con sus propios residentes, por lo que nada obliga a interpretar dicha legislación de modo que suponga que requisitos exigidos a residentes en España no sean también exigidos a residentes en otros estados miembros.

Por tanto, la conclusión final es que la reclamante no acredita estar en situación de igualdad con las IIC españolas en los aspectos que resultan relevantes para el acceso al régimen fiscal especial que demanda.

(...) el criterio expuesto ha sido confirmado por esta Sala en diversas sentencias, siendo ejemplo de ello las de 7 de julio de 2015, recursos 1009 y 1107/2013, de la sección 5ª, y la de 6 de abril de 2017, recurso 136/2017, sección 4ª.

Ahora, en sede judicial, aporta

- i) certificado emitido por la propia recurrente sobre las características de las IIC británicas,
- ii) extractos de los registros de accionistas para acreditar que cuenta con más de 100 partícipes,



- iii) extracto del balance de las cuentas anuales para acreditar que el capital social es superior al importe mínimo exigido,
- iv) declaración tributaria del Impuesto de Sociedades en el Reino Unido,
- v) v) certificado de retenciones soportadas en España por la entidad recurrente.

Se trata, no obstante, de documentos que siguen sin cumplir lo exigido por la AEAT y sin aclarar los extremos dudosos; así, o bien son certificaciones emitidas por la propia entidad recurrente, o bien extractos de documentación contable sin ninguna explicación o análisis al respecto.

Por tanto, con la documentación aportada al expediente la recurrente no cumple las exigencias probatorias necesarias para justificar la concurrencia de semejanza objetiva. La comparación ha de hacerse, no con las pautas generales que resultan de las directivas comunitarias que han regulado la materia, sino con los requisitos concretos que marca la legislación española, cuya concurrencia en el caso de autos no ha sido acreditada, lo que impide el acceso al régimen fiscal español de las IIC residentes en nuestro país".

CUARTO.- *El recurso de casación de la entidad JP Morgan European Investment Trust PLC y la oposición del Abogado del Estado.*

I.- El recurso de casación para apoyar su pretensión efectúa el siguiente reproche:

"La Sentencia de instancia infringe el artículo 14.1.l) del TRLIRNR conexión con los art 63, 64 y 65 del TFUE y de la jurisprudencia del TJLJ generando un tratamiento fiscal discriminatorio a los fondos de inversión y pensiones de países no residentes en España que, al contrario de los fondos españoles o de aquellos que cumplan los requisitos del art. 14.1.k) y 1) del TRLIRNR, no tendría derecho a recuperar las retenciones sobre dividendos gravados".

Invoca también expresamente la doctrina contenida en las sentencias de esta Sala y Sección de 27 de marzo de 2019 (rec. de casación 5405/2017 y 28 de marzo de 2019, rec. de casación 5822/2017).

II.- El Abogado del Estado, como ya ha sido indicado en los antecedentes, ha manifestado en existen razones para que la Sala dicte una sentencia de signo diferente al recogido en esas dos sentencias invocadas por el recurso de casación.

QUINTO.- *Remisión íntegra a la sentencia de esta misma Sala y Sección núm. 1581/2019, de 13 de noviembre, dictada en el recurso de casación núm. 3023/2018, y reiterada posteriormente en otros pronunciamientos.*

Un asunto en el que se abordan cuestiones de interés casacional objetivo sustancialmente idénticas a las de la presente casación ha sido abordado y resuelto por esta misma Sala y Sección en el recurso de casación núm. 3023/2018, deducido frente a una sentencia de la Sala de Madrid de igual contenido a la actual que había declarado ajustado a Derecho un acuerdo de liquidación provisional dictado por la Delegación Especial de Madrid de la AEAT, en concepto de Impuesto sobre la Renta de No Residentes (sin establecimiento permanente) del segundo trimestre de 2010 e importe de 113.510,38 euros.

En dicho recurso de casación 3023/2018 se ha dictado la sentencia núm. 1581/2019, de 13 de noviembre, a la que, por elementales exigencias derivadas de los principios de unidad de doctrina y seguridad jurídica, debemos ahora remitirnos para resolver el asunto que nos ocupa.

1.- Esta sentencia anterior de 13 de noviembre de 2019, en su fundamento de derecho (FJ) segundo, recuerda la doctrina contenida en las anteriores sentencias de 27 de marzo de 2019, rec. cas. 5405/2017, y de 28 de marzo de 2019, rec. cas. 5822/2017, y lo hace así:

"En sentencias de 27 de marzo de 2019, rec. cas. 5405/2017, y de 28 de marzo de 2019, rec. cas. 5822/2017, nos pronunciamos sobre la procedencia de la devolución de las cantidades retenidas en el IRNR a IIC no residentes miembros de la Unión Europea por vulneración del principio europeo de libertad de circulación de capitales, art. 63 del TFUE.

En estas sentencias hacíamos referencia también a las sentencias de 5 de junio de 2018, rec. cas. 634/2017, sobre fondo de pensiones, y de 5 de diciembre de 2018, rec. cas. 129/2017, sobre fondos de inversión, en las que resolvíamos sobre el devengo de intereses de demora correspondientes a la devolución de las retenciones practicadas a una institución de inversión colectiva en valores mobiliarios, sin establecimiento permanente en España, residentes en un país miembro de la UE, sobre dividendos percibidos de sociedades residentes, en las que, lógicamente, partíamos de la vulneración del citado art. 63 del TFUE.

Brevemente, recordando lo dicho anteriormente, llegamos a la conclusión de que la infracción del Derecho de la Unión Europea es clara, como se desprendía de la jurisprudencia europea, SSTJUE de 6 de junio de 2000,

Asunto C-35/98, Verkooijen; de 8 de noviembre de 2007, Asunto C-379/05, Amurta; de 17 de septiembre de 2015, asuntos acumulados C-10/14, C-14/14 y C-17/14, (...).

2.- Más adelante (FFJJ tercero y cuarto) da respuesta a esas cuestiones de interés casacional objetivo sustancialmente idénticas a las delimitadas en la actual casación.

Siendo suficiente -para llenar el requisito de motivación- con reiterar aquí la parte interpretativa contenida en dichos FFJJ tercero y cuarto en los siguientes términos literales:

"(1) (...) La primera de las cuestiones con interés casacional, *mutatis mutandis* conforme a lo ya resuelto, debe responderse en el sentido de que el diferente tratamiento tributario de los dividendos percibidos de sociedades residentes en España supone una restricción a la libre circulación de capitales contraria al Derecho de la Unión Europea.

Ahora bien, resulta necesario contar con los elementos de contraste necesarios para llegar a la conclusión de que efectivamente se produce el distinto tratamiento, no basta con la simple denominación de fondo de inversión o similar del no residente, sino que debe verificarse que efectivamente el fondo de inversión no residente posee una naturaleza comparable con los fondos de inversión residentes o de otros Estados miembros (...).

Esto es, no puede exigirse (...) la identidad absoluta entre los fondos residentes regulados en la legislación española y los no residentes, no es posible exigir dicha identidad, sino que resulta suficiente que sean similares o equivalentes, encontrando los elementos configuradores que definen IICs en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, si bien, en el caso que nos ocupa dado que la solicitud se contrae a los dividendos obtenidos en el cuarto período de 2009, y la anterior Directiva, en lo que ahora interesa, arts. 1 a 3, no entró en vigor sino hasta el 1 de julio de 2011, art. 118, es de aplicación la Directiva 85/611/CEE, del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios, siendo lo procedente que el fondo de inversión no residente que pretenda la devolución justifique que cumple las condiciones previstas para los fondos residentes, en este caso, en la Directiva 85/611/CEE; en palabras del TJUE,

"comprobar, en cooperación con las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, que desarrollan sus actividades en unas condiciones equivalentes a las aplicables a los fondos de inversión establecidos en el territorio de la Unión".

El que la normativa de referencia lo constituyan la Ley 35/2003 y el reglamento de IICs en relación con el Impuesto sobre Sociedades, lleva necesariamente a restringir el tipo de gravamen al 1% respecto de determinadas IICs que reúnan los requisitos legalmente dispuesto, pero en ningún caso sería de aplicación a los fondos no residentes, tal y como ha quedado dicho anteriormente; lo que per se conlleva la inidoneidad de la normativa nacional en exclusividad a los efectos de servir de contraste para verificar si las no residentes "operan en un marco normativo equivalente al de la Unión.

Sobre las anteriores consideraciones, en definitiva, la resolución del caso concreto pasaría por un problema meramente probatorio, esto es, probar y, en su caso, verificar que el fondo no residente de EEUU, para el año 2009, poseían un marco normativo equivalente a los de la UE (...).

(2) Dicho lo anterior la respuesta a la segunda cuestión planteada por el auto de admisión ha de contestarse en el sentido de que podrían resultar suficientes los mecanismos existentes para obtener información sobre los fondos de inversión residentes en Estados Unidos de América, la cláusula de intercambio de información prevista en el artículo 27 del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 22 de febrero de 1990, para el ejercicio de 2009".

SEXTO. - Sobre la aplicación de la doctrina expuesta al caso concreto.

En relación con la solución del caso, el FJ quinto de esa sentencia de 13 de noviembre de 2019, recordó la posición del abogado del Estado en su escrito de oposición, que consideró que de no aceptarse los argumentos hechos valer en su escrito -aceptados en parte, respecto de la suficiencia de los mecanismos de intercambio de información-, lo procedente es analizar la información obtenida y realizar la evaluación sistemática para determinar la equiparación exigida por la UE.

Y también consideró que la carga de la prueba recae sobre el interesado en obtener la devolución, y que en todo caso, de entender que la cláusula de intercambio de información es suficiente para el análisis de

comparabilidad, no debe ello dar lugar a la estimación de la pretensión actora, sino sólo a la retroacción del procedimiento para que la Administración española recabe la información necesaria.

Y ese mismo FJ quinto razonó a continuación lo que continúa

"Como en ocasiones ha señalado el TJUE,

"las autoridades tributarias de un Estado miembro están facultadas para exigir al contribuyente las pruebas que consideren necesarias para apreciar si se cumplen los requisitos de una ventaja fiscal prevista por la legislación pertinente y, por consiguiente, si procede conceder o no dicha ventaja. No obstante, el ejercicio de dicha autonomía fiscal de los Estados miembros debe hacerse respetando las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión, especialmente las establecidas por las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, lo cual entraña que los potenciales beneficiarios no residentes no pueden estar sujetos a cargas administrativas excesivas que les impidan de forma efectiva beneficiarse del régimen fiscal de que se trata".

Sin embargo, por razones obvias, la normativa española no establecía el cauce y la posibilidad de acreditar mediante un determinado medio probatorio que un fondo de inversión residente en EEUU se ajustaba a las exigencias equivalentes previstas para los fondos residentes en UE.

Tras la reforma del art. 14 del IRNR sí se prevé mecanismo para beneficiarse de la exención que prevé el art. 14.1.I), al respecto, art. 7.1.b de la OM EHA/3316/2010, mediante un certificado emitido por la autoridad competente del Estado miembro de origen de la institución en el que se manifieste que dicha institución cumple las condiciones establecidas en la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, la autoridad competente será la designada conforme a lo previsto en el artículo 97 de la citada Directiva.

Además, como ya se ha indicado, el ámbito de aplicación de esta Directiva, ni la anterior aplicable al caso por razones temporales, 85/611/CEE, alcanzaba a las instituciones residentes en terceros países.

Y señalamos -y ahora reiteramos- que estamos, pues, ante un vacío normativo al respecto, toda vez que no existía al momento de la solicitud de devolución cauce ni trámite dispuesto para poder llevarlo a efecto; cualquier exigencia formal para la efectiva realización, en los términos antes apuntados por la jurisprudencia europea, en base al alcance del principio de libre circulación de capitales, no puede ser de tanta exigencia que impida u obstaculice gravemente la obtención del beneficio que legítimamente pudiera corresponder al interesado.

Llegados a este punto ha de convenirse que se ha producido la vulneración del principio de libre circulación de capitales previsto en el art. 63 del TFUE; que la parte recurrente tiene el legítimo derecho de solicitar la devolución de la retención indebidamente realizada; y que ante el vacío legal sobre la forma en que debía articularse la solicitud y los medios para acreditar, en este caso, la equivalencia o similitud ya referida, aun cuando le correspondía a la solicitante de la devolución acreditar dicha circunstancia esencial, la misma cumplió mediante la aportación de los medios que tuvo por conveniente intentando acreditar sería y rigurosamente dicha equivalencia -la propia sentencia da cuenta de los medios utilizados y de, incluso, su mayor amplitud que en otros casos-.

Existiendo mecanismo para el intercambio de información entre España y EEUU en los términos vistos, en caso de duda correspondía a las autoridades españolas recabar la información necesaria a las autoridades de EEUU para poder comprobar dicha equivalencia.

Por tanto, al no haber actuado la Administración de dicho modo -se limitó a iniciar procedimiento de comprobación, y justificar la retención del 15% en base a la Ley IRNR y CDI- debe prosperar la pretensión actora y en su consecuencia declarar su derecho a la devolución de lo indebidamente retenido y sus intereses".

Debe añadirse que no es óbice para aplicar en la actual casación la anterior doctrina el dato de que aquí haya de ser considerado el Convenio de Doble Imposición entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 1975. Pues el contenido de sus artículos 26 y 27 presenta una sustancial coincidencia con el de los artículos que regulaban la misma materia en el Convenio de Doble Imposición entre España y los Estados Unidos de América de 1990 (sustituido en 2013).

SÉPTIMO.- Sobre las costas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, respecto de las costas de la casación, no procede hacer un pronunciamiento condenatorio sobre las mismas, y por lo que se refiere a las de la instancia, a tenor del artículo 139.1 LJCA, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, habida cuenta de las dudas de derecho que suscita la cuestión litigiosa.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1.- Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia, por remisión a la sentencia de esta Sala de 13 de noviembre de 2019, pronunciada en el recurso de casación núm. 3023/2018.

2.- Declarar haber lugar al presente Recurso de Casación número 183/2019 interpuesto por la representación procesal de la entidad JP Morgan European Investment Trust PLC contra la sentencia núm. 480/2018, de 22 de octubre de 2018, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 30/2018), sobre impuesto sobre la renta de no residentes, sentencia que se casa y anula.

3.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad la entidad JP Morgan European Investment Trust PLC contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 14 de noviembre de 2017, por la que se desestiman la reclamaciones económico-administrativas dirigida frente al rechazo de la solicitud relativa a devolución en concepto de impuesto sobre la renta de no residentes, primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2010 y cuantía total de 214.360,21 euros, anulando las expresadas resoluciones por su disconformidad a Derecho y declarando el derecho de la referida entidad a la devolución interesada por tal concepto (de lo efectivamente ingresado en exceso por esos cuatro trimestres) más los intereses legales correspondientes.

4.- No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni sobre las de la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Nicolás Maurandi Guillén D. José Díaz Delgado

D. Ángel Aguallo Avilés D. José Antonio Montero Fernández

D. Francisco José Navarro Sanchís D. Jesús Cudero Blas

D. Isaac Merino Jara D^a. Esperanza Córdoba Castroverde

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. Don Nicolás Maurandi Guillén, Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del Tribunal Supremo, lo que como Letrado de la Administración de Justicia, certifico.-